

RECURSO CÍVEL Nº 5063136-71.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO SOUZA GUIMARAES (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. TRABALHO OFFSHORE. IRPF SOBRE FOLGAS INDENIZADAS E SIMILARES. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO DA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO DA 8ª TURMA NO QUE DIZ RESPEITO A PARCELAS DIFERENTES DE "FOLGAS INDENIZADAS", INDENIZAÇÃO DE FERIADOS, REPOUSO E SIMILARES INDENIZATÓRIOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE ABONO ACT 2023-205. VALORES SUJEITOS À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA INDENIZATÓRIA DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NÃO GOZADO. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, bem como VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, para a reforma em parte da sentença nos moldes da fundamentação. Condeno a União ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da condenação imposta em sentença. Sem honorários pela autora, porquanto vencedora, mesmo que em parte. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5063136-71.2024.4.02.5101

510015733317 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5063136-71.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO SOUZA GUIMARAES (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de ação em face da União - Fazenda Nacional em que a parte autora, empregada de empresa de exploração de petróleo ou afim, pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre rubricas referentes a pagamentos em contracheque que considera indenizatórios, com a respectiva repetição do indébito tributário.

A sentença julgou a lide nos seguintes termos:

*"Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.259/2001, **PASSO** à fundamentação.*

FUNDAMENTAÇÃO.

Trata-se de ação pelo efeito do Juizado Especial Cível, ajuizada por CLAUDIO ROBERTO SOUZA GUIMARAES em face de UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, objetivando a declaração de não incidência de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF -, incidente sobre o montante recebido a título de **Repouso semanal remunerado não gozado, Abono e Adicional de intervalo HRA (horas repouso)** e a restituição das parcelas indevidamente recolhidas, devidamente atualizadas.

Os trabalhadores de empresa, em regime offshore, estão vinculados a regime laboral peculiar, previsto na Lei n.º 5.811/72, ante as peculiaridades do setor, sobretudo impossibilidade de interrupção do trabalho.

Nessa senda, trabalham em regime de turnos ininterruptos diferenciados, com direito a uma folga para cada dia trabalhado embarcado, o que na prática, faz com que o funcionário trabalhe 14 dias consecutivos em plataforma e goze de 14 dias de folgas.

Em razão da imprescindível necessidade de continuidade operacional e, garantia da normalidade das operações, foram estabelecidas várias peculiaridades como sobreaviso, possibilidade de jornada de até 12 horas, supressão/indenização/adiamento de folgas, imposição de limites e, claro, retribuição diferenciada.

Tal continuidade pode dar ensejo a acréscimo de remuneração com caráter de hora extra ou, ainda, promover alteração da jornada de trabalho a repercutir no exercício de direitos como folga ou férias, o que ensejará indenização.

Na primeira hipótese, há o fundamento dos artigos 2º a 8º da Lei 5.811/72 pelo qual tem-se a possibilidade de manutenção do empregado no posto de trabalho, sempre que imprescindível à continuidade operacional.

No que tange à indenização por direito não usufruído com alteração do regime de trabalho, há previsão no artigo 9º da Lei 5.811/1972:

"Art. 9º Sempre que, por iniciativa do empregador, for alterado o regime de trabalho do empregado, com redução ou supressão das vantagens inerentes aos regimes instituídos nesta lei, ser-lhe-á assegurado o direito à percepção de uma indenização."

E, acresce-se à legislação, os acordos coletivos de uma categoria de trabalho organizada e forte.

No tocante ao objeto da lide, há pleito de não incidência de Imposto de Renda sobre determinadas rubricas, o que torna necessário aferir se as verbas mencionadas dizem respeito a retribuição pelo trabalho extra - hora extra retribuída (remuneração e acréscimo patrimonial), ou pagamento de indenização pela supressão de um direito (indenização e recomposição de patrimônio).

Nos termos do art. 153, inciso III, da Constituição Federal, o imposto de renda tem como fato gerador a obtenção de renda ou proventos de qualquer natureza.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 43, de forma a delimitar a previsão constitucional, traz como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; ou proventos de qualquer natureza, como os acréscimos patrimoniais não considerados renda.

Nos termos da lei, portanto, depreende-se que aquilo que não constitui renda ou acréscimo patrimonial não pode ser passível de incidência do Imposto de Renda. Não é por motivo outro que se torna ilegítima, via de regra, a incidência de tributária sobre verbas de caráter indenizatório, salvo raríssimas exceções. Patente que indenização, em sua natureza, não é renda, mas, reparação de dano.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.116.460/SP, de que para que se verifique o fato gerador do Imposto de Renda é imprescindível a constatação do acréscimo patrimonial.

Por tal panorama, estabelecidas as balizas para se concluir pelo caráter, do pagamento/rubrica, como remuneratória sobre a qual indicará a tributação a título de imposto de renda ou indenizatória sobre a qual não existirá tributação, é ônus da parte autora comprovar o fundamento do pagamento da verba.

Assim, deverá comprovar o caráter indenizatório com a supressão de direito:

"TRIBUTÁRIO - FOLGA INDENIZADA E INDENIZAÇÃO FOLGA -NOMENCLATURA DIVERSA - Não há obrigação de utilização e nem uniformização da nomenclatura das rubricas pagas pelos empregadores celetistas a seus empregados, ainda que do mesmo setor e para pagamento das hipóteses chanceladas no acordo coletivo da categoria. **Dessa forma não se pode presumir que verba com nomenclatura diversa da consagrada pela TNU - FOLGA INDENIZADA - refira-se a mesma situação fática. Necessidade concreta de comprovação pela parte autora do fundamento do pagamento para julgamento com observância das garantias do devido processo legal.** (Sessão do dia 20/8/2024, sessão ordinária, e proc, RECURSO CÍVEL Nº 5011094-70.2023.4.02.5104/RJ, combinado com o RECURSO CÍVEL n.º 5000611-41.2024.4.02.5105, Relatora Dra. Daniella Motta) (grifei)"

Frente a isso, passa-se a analisar o caráter das rubricas sobre as quais pretende a parte autora o reconhecimento da não incidência e, ainda, a repetição de indébito por desconto já verificado.

Rubricas sobre as quais não incide Imposto de Renda

Adicional de Intervalo HRA (Horas Repouso)

Os valores referentes à Hora Repouso Alimentação (HRA) se consubstanciam em pagamentos decorrentes da disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades durante o intervalo destinado ao repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei nº 5.811/71:

Art. 2º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o empregado será mantido em seu posto de trabalho em regime de revezamento.

(...)

§ 2º Para garantir a normalidade das operações ou para atender a imperativos de segurança industrial, poderá ser exigida, mediante o pagamento previsto no item II do art. 3º, a disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação.

A Lei Federal nº 5.811/72 assegura ao empregado sujeito ao regime de revezamento de oito horas o direito ao pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação suprimida em decorrência da necessidade de se garantir a normalidade das operações ou de atender a imperativos de segurança industrial, referentes à prestação de serviços nas atividades que relaciona em seu art. 1º.

Por sua vez, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) estabelece que, no trabalho contínuo, cuja duração exceda de seis horas, é obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação de, no mínimo, uma hora, cabendo ao empregador remunerar o empregado por eventual descumprimento dessa determinação, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho, com base no artigo 71, § 4º, in verbis:

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

(...)

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as parcelas relativas ao intervalo intrajornada e interjornada não usufruídas têm natureza salarial, de modo que incidem sobre elas a tributação nas situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.467, de 13 de julho de 2017, in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de Hora Repouso Alimentação - HRA, prevista nos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT. 2. O acórdão embargado consignou que tal verba "[...] reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória, pois seu escopo é recompor direito legítimo do empregado suprimido em virtude das vicissitudes da atividade laboral, assumindo perfil de genuína compensação, de verdadeira contrapartida a que o empregador está obrigado, por lei, a disponibilizar ao obreiro, em virtude da não fruição do direito ao intervalo para refeição e repouso que lhe é garantido, imprescindível ao restabelecimento do seu vigor físico e mental". 3. Partindo da premissa de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza indenizatória, concluiu que sobre ela não deve incidir a contribuição previdenciária patronal (art. 22, I, da Lei 8.212/1991). 4. O julgado apontado como paradigma, por sua vez, assentou: "a 'Hora Repouso Alimentação - HRA' [...] é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador", configurando, assim, "retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991". 5. É patente a similitude fática entre os acórdãos confrontados, bem como a divergência entre as soluções jurídicas adotadas em cada caso. PRECEDENTES DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMA DO STJ 6. A Primeira Turma reconheceu que a HRA reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória em mais um precedente: REsp 1.328.326/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p./ acórdão Min.Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.5.2017. 7. Na Segunda Turma, prevalece a compreensão de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza remuneratória, devendo incidir sobre ela a contribuição previdenciária patronal. Precedentes: AgInt no REsp 1.727.114/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019; AgInt no AREsp 1.122.223/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.8.2019; AgRg no REsp 1.449.331/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016; REsp 1.144.750/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2011; EDcl no REsp 1.157.849/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.5.2011. NATUREZA JURÍDICA DA HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO 8. A Hora Repouso Alimentação - HRA constitui verba paga ao trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei 5.811/1972. O pagamento por essa "disponibilidade do empregado" é feito nos termos dos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT. 10. A Hora Repouso Alimentação - HRA é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador. Ou seja, o trabalhador recebe salário normal pelas oito horas regulares e HRA pela 9ª (nona) hora, em que ficou à disposição da empresa. 11. Inexiste simplesmente supressão da hora de descanso,

hipótese em que o empregado ficaria 8 horas contínuas à disposição da empresa e receberia por 9 horas (haveria "indenização" pela hora de descanso suprimida). 12. O empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, embora uma dessas horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de situação análoga à hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição previdenciária. 13. Ao contrário do afirmado no acórdão embargado, a HRA possui nítida natureza remuneratória, submetendo-se à tributação pela contribuição previdenciária patronal, nos termos dos arts. 22, I, e 28 da Lei 8.212/1991. 14. Tratando da incidência da contribuição previdenciária sobre a HRA, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.039.689/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.9.2017), afirmou: "Desse modo, não diverge o Tribunal a quo do entendimento da Corte no sentido da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre verbas remuneratórias, conforme ficou deliberado no julgamento do RE nº 565.160/SC (Tema 20 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet). Verifico que, nessa decisão, a Corte se debruçou sobre o alcance da expressão "folha de salários", contida no art. 195, I, "a", da Constituição Federal, que é base de cálculo da exação em tela". 15. Em obiter dictum, impende ressaltar que a redação do art. 71, § 4º, da CLT foi alterada pela Lei 13.467/2017: "A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho". 16. A compreensão esposada abrange apenas os pagamentos e recolhimentos realizados antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017, uma vez que a nova redação do art. 71, § 4º, da CLT não foi objeto de discussão no presente caso. CONCLUSÃO 17. Embargos de Divergência providos, para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a Hora Repouso Alimentação - HRA, até a entrada em vigor da Lei 13.467/2017. (EREsp 1619117/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 08/05/2020)"

Nada obstante, a Lei Federal nº 13.467/2017, no art. 71, § 4º, trouxe alterações à CLT e dispôs expressamente que o pagamento de intervalo intrajornada suprimido tem natureza indenizatória:

"Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.

§ 2º - Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.

§ 3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Redação dada pela Lei 13.467, de 2017).

A questão foi objeto de apreciação pela Turma Nacional de Uniformização (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 0520381-15.2020.4.05.8400/RN), oportunidade na qual restou fixada a seguinte tese (TEMA 306):

"Com o advento da Lei nº 13.467, de 13/07/2017, que deu nova redação ao § 4º do art. 71 da CLT e estabeleceu expressamente a natureza indenizatória do pagamento operado pela supressão do intervalo intrajornada, habitualmente conhecido como Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA), em conformidade com a proteção constitucional à saúde do trabalhador (arts. 7º, XXII, 194, caput, 197 e 200, II, bem como art. 5º, § 2º c.c. arts. 4º e 5º da Convenção 155 da OIT, incorporada ao direito interno pelo Decreto n. 1.254/94, hoje consolidada no Decreto n. 10.088/2019 e o art. 7º, do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, incorporado ao direito interno pelo Decreto n. 591/92), não incide imposto de renda sobre a verba paga a tal título"

Dessa maneira, conclui-se que prevalece o entendimento de que os valores percebidos a título de Hora Repouso Alimentação (HRA) detém natureza indenizatória, não devendo sofrer a incidência de imposto de renda.

No caso, alega a parte autora que desenvolve sua rotina de labor em plataforma de exploração de petróleo, sem usufruir do intervalo para descanso e alimentação, tal como previsto no art. 71 da CLT, ante a especificidade de suas atividades laborais e exigência do empregador.

Em consequência, recebe mensalmente a título de Hora Repouso Alimentação (HRA), verba que a empresa empregadora descreve como ADICIONAL DE INTERVALO (ADIC DE INTERVALO 32,50%), quantia que, como visto, detém natureza indenizatória, uma vez que corresponde a compensação por não usufruir do intervalo intrajornada, razão pela qual não deve haver a incidência de imposto de renda.

Rubricas sobre as quais incide Imposto de Renda

Descanso semanal remunerado (Repouso semanal remunerado não gozado)

Dada as peculiaridades do regime de trabalho off shore do autor, com períodos em alto mar e períodos de descanso em terra, é evidente que haverá períodos de trabalho tanto no repouso semanal remunerado, que ocorre, em regra, aos domingos, quanto nos dias de feriados nacionais, como decorrência natural e lógica do regime.

Portanto, não há supressão do descanso ou do feriado, mas sim sua mera postergação para o período de repouso contínuo em terra até o próximo embarque, havendo inclusive ganho adicional pelo trabalho nesses dias, mas sem que significa indenização.

Nesses termos, **ainda assim, ocorre o pagamento de adicional na forma de hora extra**, não se confundindo com a supressão dos dias destinados à folga do trabalhador, os quais são remunerados por outras rubricas, como as anteriormente explicitadas.

Assim, deve ser reconhecida a incidência do imposto de renda sobre a referida rubrica dada sua natureza remuneratória e de acréscimo patrimonial no regime de trabalho off shore. Reconhecer a não incidência tributária sobre essas verbas seria o reconhecimento de não incidência do IRPF sobre verbas cuja natureza é nitidamente remuneratória, consoante o art. 43 do CTN.

Abono ACT 2023-2025

Cabe à parte autora demonstrar sob quais razões e fundamentos a rubrica Abono ACT 2023 poderia ser enquadrada como verba de caráter indenizatória.

No caso, o(a) autor(a) alega que "O abono, em questão, trata-se daquele pago por ocasião do Acordo Coletivo 2023, pois tal verba possui expressa natureza indenizatória, conforme preceitua o art. 457, § 2º, da CLT, com redação dada pela Lei 13.467/17".

Em análise ao acordo coletivo anexado no Evento 01, verifico que o abono em questão é meramente um acréscimo patrimonial pago em benefício dos empregados em função do encerramento das negociações coletivas e da celebração de um novo instrumento coletivo para os próximos 2 (dois) anos, ACT 2023-2025. Trata-se mero "prêmio", possuindo nítido caráter de acréscimo patrimonial. Não há nada de natureza indenizatória na rubrica em questão:

Cláusula 114. Abono ACT 2023-2025

A Companhia pagará, de uma só vez, um abono a todos os empregados que estiveram em efetivo exercício em 31/08/2023, nos termos do parágrafo 2º do art. 457 da CLT, **em função do encerramento das negociações coletivas e da celebração de um novo instrumento coletivo para os próximos 2 (dois) anos, ACT 2023-2025.**

I. Excepcionalmente, serão contemplados no referido pagamento os empregados admitidos na Companhia entre os dias 01/09/2023 e 30/11/2023, e que estejam em efetivo exercício em 30/11/2023.

Por fim, é imperioso ressaltar que o § 2º do art. 457 da CLT foi claro ao declarar que os abonos não constituem base de incidência de qualquer encargo **trabalhista** e **previdenciário**. Ou seja, em silêncio elocuente, não estabeleceu nenhuma isenção tributária genérica:

Art. 457. (...)

§ 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Segundo o princípio da legalidade, em regra, o intérprete não deve restringir ou ampliar sua interpretação em que o legislador não o fez, sob pena de malferir a separação entre os poderes.

Não integrar a remuneração do empregado não significa que seja verba indenizatória, o que depende da demonstração concreta de que resultaria da conversão de direito que não foi oportunamente gozado pelo trabalhador, ainda que por opção própria, quando seria dotado de natureza indenizatória e destituído de capacidade de incremento patrimonial. O que não é a hipótese dos autos.

Assim, restando evidenciada a natureza de proventos de qualquer natureza da referida rubrica (art. 43, II, do CTN), pois afastado o caráter de renda (art. 43, I, do CTN) por força de lei por não se enquadrar no produto do trabalho (art. 457, § 2º, da CLT), tem-se pela incidência do IRPF sobre a verba em questão, dado o nítido caráter de acréscimo patrimonial.

De igual modo quanto à rubrica Dif. Abono ACT 2023, sem caráter indenizatório para afastar a incidência tributária.

Fixadas tais premissas, deve ser julgado parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a restituir o valor retido referente a Imposto de Renda incidente sobre o montante recebido a título de **Adicional de intervalo HRA (horas repouso)**, de caráter indenizatório, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contado retroativamente da data do ajuizamento da presente demanda.

Assim, conclui-se que o autor possui o direito à restituição dos valores descontados indevidamente, observado o prazo prescricional quinquenal, contado retroativamente a partir da data de ajuizamento da presente demanda, nos termos do que determina o art. 168 do CTN e art. 3º, da Lei Complementar nº 118/2005, bem como conforme a interpretação determinada no RE nº 566.621 julgado em repercussão geral.

Por oportuno, cumpre asseverar que, sobre o indébito tributário a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, as parcelas devidas deverão ser remuneradas, desde quando descontadas, pelo índice da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, o qual representará, simultaneamente, atualização monetária e juros de mora, não podendo incidir cumulativamente com outro índice de correção monetária.

Isso porque a taxa de juros a ser aplicada em favor do sujeito passivo é a mesma que a lei prevê que o Fisco poderá cobrar do contribuinte em caso de tributo atrasado. Ademais, a utilização da SELIC em caso de restituição de tributos foi determinada pela Lei nº 9.250/95 e é inacumulável com outro índice de correção por já englobá-la.

Ressalte-se que o presente caso não constitui hipótese de sentença ilíquida, mas de determinação do valor da condenação por simples cálculo aritmético, a ser apresentado em fase de execução, antes da expedição do requisitório.

DISPOSITIVO.

*Ante o exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos veiculados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:*

*a. **DECLARAR** a inexistência de relação jurídico-tributária no tocante ao imposto de renda incidente sobre as parcelas referentes às rubricas "Adicional de intervalo HRA (horas repouso)", de natureza indenizatória.*

Após o trânsito em julgado, a presente sentença tem força de Ofício para que a fonte pagadora (empregador) cesse a retenção na fonte do Imposto de Renda da Pessoa Física em relação à rubrica mencionada.

*b. **CONDENAR a ré a restituir**, ao autor, após o trânsito em julgado os valores indevidamente recolhidos a título Imposto de Renda, observando-se o prazo prescricional quinquenal, contado retroativamente a partir da data de ajuizamento da presente demanda e a incidência da Taxa **SELIC** desde o pagamento indevido.*

Novamente, o presente caso não constitui hipótese de sentença ilíquida, mas sim de que a determinação do valor da condenação depende de simples cálculo aritmético, a ser apresentado em fase de execução, antes da expedição do requisitório.

Sem custas e sem honorários (artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/01).

(...)"

Ambas as partes recorrem da sentença.

A Fazenda Nacional reitera suas razões de contestação, argumentando que os valores recebidos com a rubrica "**Adicional de intervalo HRA (horas repouso)**" não constituem verbas de caráter indenizatório, que representam claro aumento patrimonial da parte autora, e sobre as quais deve incidir imposto de renda.

A parte autora, por sua vez, reafirma os argumentos da petição inicial, alegando que as rubricas não concedidas na sentença (**repouso semanal remunerado não gozado e abono ACT 2023-2025**) constituem verbas de natureza indenizatória e não devem sofrer a incidência de imposto de renda.

É o breve relatório.

VOTO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEMA

Cinge-se a questão ao pedido de isenção de imposto de renda sobre verbas de alegada natureza indenizatória recebidas por trabalhadores de empresas em regime *offshore* e pagas segundo o disposto pela Lei 5.811/72.

O trabalhador embarcado em navios sonda, atividades similares e/ou plataformas de exploração de petróleo tem uma jornada diferenciada e faz jus a dias de folga para os dias trabalhados, conforme previsto, tanto na lei de referência quanto nos contratos de trabalho e convenções coletivas do setor. Caso não goze a folga prevista, deverá ser indenizado.

A jurisprudência, após alguns debates, pacificou o entendimento de que **não incide imposto de renda sobre a indenização referente à “folga trabalhada e não gozada”** e, portanto, se houve esse desconto, cabe o pleito de repetição de indébito, conforme:

TNU - Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais - PEDILEF: 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020. Tese: “não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas”.

De fato, o regime de trabalho é peculiar e a Lei 5.811/72 prevê a possibilidade de manutenção do marítimo no posto de trabalho sempre que necessária à continuidade operacional. Nesse caso há pagamento de valores adicionais diferenciados por hora trabalhada e se assegura um repouso compensatório em período subsequente. Mesmo em dias que seriam folgas, o marítimo pode trabalhar e ficar à disposição do empregador se for necessário. Nesse caso se trata de trabalho extraordinário e é pago de forma diferenciada e majorada nos termos contratuais.

As rubricas em contracheques nos setores são variadas, mas espelham períodos de **dobras ou similares, sobreavisos, quarentenas, cursos regulares e treinamentos específicos, entre outras nomenclaturas e especificidades.**

Como se trata de vínculo celetista contratual e não estatutário legal, não há padronização de nomenclatura para rubricas de pagamento nos acordos coletivos, contratos ou contracheques recebidos de cada empresa. Assim sendo, são inúmeras as parcelas semelhantes, mas com nomes diferentes, que se espelham nos documentos apresentados nos processos em curso, o que dificulta a análise da natureza indenizatória ou remuneratória da verba. Por vezes, a mesma nomenclatura de rubrica paga por duas ou mais empresas não necessariamente significa a mesma situação fática relativa à atividade do empregado.

No campo tributário, *“não é o nomen juris, mas a natureza jurídica da verba que definirá a incidência tributária ou não. O fato gerador de incidência tributária sobre renda e proventos, conforme dispõe o art. 43 do CTN, **é tudo que tipificar acréscimo ao patrimônio material do contribuinte.**”* Precedentes da Primeira Seção deste Tribunal: EREsp 695.499/RJ, Rel. Min. Herman Benjamim, em 09/05/2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008, p. 1. 5”. (EResp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008)

Realmente não pode ser afastada a incidência tributária de uma verba, apenas pela sua nomenclatura, ou por vontade das partes. Assim textualmente dispõe o CTN em seu art. 4º:

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.

Também em conformidade ao Código Tributário Nacional (art. 108 c/c art. 111), a legislação tributária deverá ser interpretada em sua **literalidade** em situações as quais haja a suspensão ou a exclusão do crédito tributário, a outorga de isenção ou a dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. **Portanto, na temática dos autos, realmente apenas a verba que é paga sem dúvida como forma de indenização e não de remuneração por serviços normais, extras ou extraordinários, deve ser excluída da tributação por não perfazer hipótese de incidência tributária.**

Verifica-se nos inúmeros feitos em tramitação sobre a temática, que a argumentação trazida pela parte autora de que se trata de verba indenizatória, se calca apenas em acordo geral coletivo da categoria (uma categoria profissional é composta por trabalhadores que laboram em múltiplos seguimentos, funções, jornadas, atividades e locais, não há completa homogeneidade para a situação laboral dentro de cada categoria) e, algumas vezes, em declaração contraditória da empresa empregadora já que descontou o imposto de renda na fonte, porém ao final declarou que sabidamente descontou imposto de renda de verba indenizatória referente à folga não gozada, mas que não classificou em rubrica como “folga indenizada”.

Por certo que a União Federal não participa de acordos coletivos e nem chancela contratos trabalhistas. Assim não pode se responsabilizar simplesmente por devolver como indébito o que a empresa então entendeu como remuneração, **muito menos devolver imposto sem provas fáticas trazidas pelo autor da natureza cabal de indenização daquela rubrica específica - independentemente de sua nomenclatura, de acordo coletivo ou declaração geral da empresa. Ou seja, prova no sentido de que aquela rubrica, para aquele trabalhador específico e naquela competência específica, foi paga como compensação por folga não gozada, e não simplesmente pela folga trabalhada que posteriormente poderá ser gozada. São contratos individuais de trabalho e cada trabalhador pode ter um calendário laboral diferenciado, acordo individual com a empresa e remuneração diferenciada.**

Assim, não havendo nos autos a prova indubitável no sentido de que a(s) rubrica(s) é (são) de fato similar(es) a “folgas indenizadas porque não gozadas a tempo ou a posteriori” - ônus probatório do autor ainda na fase de instrução - é inviável excluir a verba da incidência tributária, pois certamente indica pagamento por horas extras a serviço do empregador.

Por outro lado, não é possível se cindir a natureza de uma rubrica estipendial, para ser indenizatória frente ao direito tributário e remuneratória para fins trabalhistas ou previdenciários. Estaria o trabalhador se beneficiando em todas as esferas de forma irregular, pois prefere manter a rubrica como remuneratória para finalidade salarial, trabalhista e previdenciária, mas na Justiça Federal requer a devolução do imposto de renda, querendo que seja considerada verba indenizatória.

Portanto, caso entendesse a parte autora que está errônea a nomenclatura de suas rubricas em holerites já que deveriam sinalizar serem lançadas como “folgas indenizadas”, o melhor caminho seria pleitear tal alteração junto ao empregador, e não trabalhar uma interpretação de forma individual, na Justiça Federal, apenas para fins de recebimento tributário de uma rubrica diversa e período específico, com condenação ao Fisco.

Como nada é feito perante o empregador, que não é réu na Justiça Federal no campo tributário, e que continuará descontando imposto de renda de parcelas ditas indenizatórias com nomenclaturas variadas, a tendência que já estamos experimentando no Judiciário Federal, é a proliferação sem fim desses processos, com multiplicação de feitos similares para cada autor, cada um com períodos diversos e rubricas diversas, em flagrante risco de burla ao juízo natural e ao teto dos Juizados Federais.

Desse modo, não havendo a prova específica de que, para aquele autor, a verba foi paga de forma indenizatória, mas com irregular desconto de imposto de renda, entende-se que se trata de verba remuneratória por horas extras ou extraordinárias, que possam até se referir a dias de descanso, mas seriam descansos que posteriormente seriam desfrutados ou compensados.

Conforme entendimento pacificado no STJ, Súmula 463, incide imposto de renda sobre as horas extras:

“Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.”

Na mesma linha de raciocínio, importante asseverar que o STJ - Superior Tribunal de Justiça considerou que a verba denominada **IHT - Indenização por Horas Trabalhadas** - recebida por funcionários da Petrobrás, mesmo sendo fundada em acordo coletivo - como de caráter remuneratório e portanto hipótese de incidência de imposto de renda - **STJ TEMA 167** - julgado na sistemática dos recursos repetitivos de controvérsia- **EREsp 939.974-RN**, DJe 10/11/2008, e **EREsp 979.765-SE**, DJe 1º/09/2008.

No mais, também importa à Justiça Federal analisar - para fins de posicionamento tributário - o enfrentamento trabalhista de pagamentos ao trabalhador.

Nessa linha, se identifica que valores referentes a: **ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos** não integram a remuneração do empregado e **não seriam, portanto, hipótese de incidência de encargo trabalhista, previdenciário e tributário.** Aqui cabe a citação do art. 457, § § 1º e 2º CLT:

§ 1º Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.

§ 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Já no que diz respeito a pagamentos de folgas a esse setor marítimo, a Justiça laboral tem entendido de forma pacífica, que pagamentos de períodos de descanso trabalhados seriam horas extras, conforme, com grifos nossos:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. JORNADA DE TRABALHO DE MARÍTIMO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS FIXAS. PREVISÃO EM INSTRUMENTO NORMATIVO. VALIDADE. DADAS AS PECULIARIDADES DO TRABALHO PELO MARÍTIMO, MORMENTE O LONGO PERÍODO EMBARCADO, CONSIDERA-SE VÁLIDA CLÁUSULA EM ACORDO COLETIVO QUE PREVÊ HORAS EXTRAS FIXAS, CUJO PAGAMENTO OCORREU EM RUBRICA ESPECÍFICA. ISSO PORQUE O PAGAMENTO DE TAIS HORAS ERA SEMPRE EFETUADO,

INDEPENDENTEMENTE DE TER HAVIDO A PRESTAÇÃO OU NÃO DE SERVIÇO, AI TAMBÉM SE INCLUINDO OS PERÍODOS DE DESCANSO. REGISTRE-SE, AINDA, QUE O ADICIONAL APLICADO ERA O DE 100%, PORTANTO EM MONTANTE SUPERIOR AO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO ADICIONAL DA HORA SUPLEMENTAR. TAL DISPOSIÇÃO COLETIVA NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE, POIS ALÉM DE OBSERVAR AS PARTICULARIDADES E CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO TRABALHO PRESTADO, APRESENTA-SE VANTAJOSA AO TRABALHADOR. LOGO, NÃO CABE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA REFERIDA CLÁUSULA PLEITEADA PELO AUTOR. APELO IMPROVIDO. (TRT-19 - RECURSO ORDINÁRIO.: 0000413-71.2016.5.19.0010, RELATOR: MARCELO VIEIRA, DATA DE PUBLICAÇÃO: 29/09/2017)

JORNADA DE TRABALHO. MARÍTIMO. NORMA COLETIVA. PRÉ-FIXAÇÃO DE HORAS EXTRAS. CONSIDERA-SE VÁLIDA A ESTIPULAÇÃO, POR MEIO DE REGULAR NEGOCIAÇÃO COLETIVA, DO PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) HORAS EXTRAS FIXAS POR MÊS, INCLUINDO O PERÍODO DE FOLGA, ASSIM COMO, A COMPENSAÇÃO DA JORNADA POR MEIO DA ESCALA DE 28X28, PARA O TRABALHADOR MARÍTIMO, DADAS AS PECULIARIDADES EM QUE O TRABALHO É DESENVOLVIDO. (TRT-1 - ROT: 01012024220215010483, Relator: ALVARO ANTONIO BORGES FARIA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Quarta Turma, Data de Publicação: DEJT 2023-04-20)

JORNADA DE TRABALHO DO MARÍTIMO. NADA A REFORMAR NA R. SENTENÇA QUE, BASEADA NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, E DIANTE DA DIVERSIDADE DO NÚMERO DE HORAS LABORADAS PELO AUTOR. MANTÉM-SE A DECISÃO. INTEGRAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CASO EM QUE DESCABE A INTEGRAÇÃO, HAJA VISTA NÃO CONSTAR DO PETITÓRIO EXORDIAL. **DOMINGOS E FERIADOS TRABALHADOS EM DOBRO. HIPÓTESE QUE ACATA-SE A TESE EXORDIAL, DE EM HAVENDO TRABALHO EM DIAS DESTINADOS AO REPOUSO, O LABOR NESTE CASO DEVE SER REMUNERADO EM DOBRO. CORRETA A DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA. RECONHECIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS COM 40%. O PAGAMENTO DO FGTS DECORRE DA CONDENAÇÃO EM VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. MANTÉM-SE, PORTANTO A DECISÃO (...) (TRT-4 - RO: 1227199192104001 RS 01227-1991-921-04-00-1, RELATOR: ANTONIO JOHANN, DATA DE JULGAMENTO: 24/05/1994, 1ª VARA DO TRABALHO DE RIO GRANDE (D))**

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. 1) INTEGRAÇÃO DO BÔNUS OFFSHORE. PRÊMIO. O nomen iuris da parcela paga ao empregado como prêmio, não tem o condão de lhe retirar a feição salarial. O relevante para caracterizar determinada verba como salário é o fato de ter sido instituída em razão do contrato de trabalho e sua habitualidade de pagamento.(...). 2) HORAS EXTRAS NOS DIAS EMBARCADOS ALÉM DO 14º DIA E FOLGAS SUPRIMIDAS. ESCALA 14X14. É incontroverso que, na escala 14 x 14, estabelecida no acordo coletivo da categoria, o empregado deveria gozar de 14 dias de folga após 14 dias trabalhados, de modo que a cada dia de trabalho, corresponde um dia de folga. **Portanto, se o empregado deixa de gozar da folga a que teria jus antes ou após o embarque, deve ser remunerada a folga suprimida ou concedida folga compensatória. Se o trabalhador ainda trabalhar no dia em que deveria estar folgando, é evidente que essas horas extras devem ser remuneradas, pois a concessão de folga compensatória não tem o condão de, simultaneamente, compensar o repouso não fruído e também as horas trabalhadas. (TRT-1 - ROT: 01002218120195010483 RJ, Relator: EVELYN CORREA DE GUAMA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/04/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: 26/04/2022) (Grifo nosso)**

A nossa Turma Regional de Uniformização na 2ª Região- TRU decidiu, em sessão no dia 21 de outubro de 2024, que rubricas denominadas "DOBRAS" em muitas de suas nomenclaturas, têm caráter remuneratório (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível (TRU) Nº **5016322-98.2024.4.02.5101/RJ** e Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível (TRU) Nº **5132699-89.2023.4.02.5101/RJ**).

Após a fundamentação acima, ressalto que a 8ª Turma Recursal tem decidido que, como regra, **somente seria objeto de repetição de imposto de renda o pagamento feito com desconto de IRPF por: folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repousos não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA.**

Já outras rubricas que são com regularidade inseridas em contracheques no setor, indicam no entender da 8ª Turma pagamento de trabalho extraordinário, imprescindível à continuidade operacional, **como por exemplo dobras e similares; períodos de sobreaviso e pré-embarque; indenização política de viagem; períodos de quarentena; dias de semana, feriados e dias de folga que possam posteriormente serem gozados; adicional de confinamento; períodos de treinamentos e cursos em serviço; outras vantagens da categoria, todos qualificados na seara trabalhista e em acordos coletivos como horas extras e/ou vantagens remuneratórias com incidência portanto de imposto de renda.**

Ressalto que a 8ª Turma também fechou posição no sentido de que compete unicamente à parte autora comprovar - ainda na inicial ou pelo menos até o final da fase de conhecimento da lide - a natureza indenizatória da rubrica espelhada especificadamente em seu contracheque. Não havendo essa comprovação, o pedido deve ser desprovido.

O CASO CONCRETO

A despeito das fartas considerações acima sobre o tema, feitas de forma meramente argumentativa envolvendo inúmeras rubricas remuneratórias eventualmente pagas aos trabalhadores de empresas de exploração de petróleo e similares e em grande parte já analisadas por esta Turma em recursos anteriores - este voto passa agora a analisar especificadamente o recurso apresentado neste processo e, portanto, serão analisadas somente as rubricas destacadas na inicial, que estejam presentes nos contracheques e que sejam objeto da sentença e do recurso.

Recorrem ambas as partes da sentença de procedência parcial do pedido de repetição de imposto de renda incidente a título de "Adicional de intervalo HRA (horas repouso)", de repouso semanal remunerado não gozado e de abono ACT 2023-2025.

Sobre a controvérsia segue a Turma o precedente da TNU, PEDILEF 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020, que firmou a seguinte tese: *"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas"*.

Como a argumentação acima neste voto demonstra que, em tese, somente o pagamento de folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repouso não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA, seriam objeto de não incidência de imposto de renda, apenas as rubricas que espelhariam essa natureza indenizatória que sejam constantes da inicial, do pedido e da sentença, mereceriam análise para devolução de indébito tributário.

Quanto às demais rubricas espelhadas em contracheques e planilhas, mas que diferem daquelas aqui logo acima mencionadas, reporto-me às considerações feitas na parte inicial deste voto, entendendo pela natureza remuneratória das verbas e incidência de imposto de renda.

Desse modo, a sentença deve ser reformada, a fim de que o pedido seja julgado:

I) **PROCEDENTE** em relação ao **repouso semanal remunerado não gozado** e ao **"Adicional de intervalo HRA (horas repouso)"**, dotados de natureza indenizatória; e

II) **IMPROCEDENTE** quanto ao **Abono ACT 2023-2025**, que apresenta caráter remuneratório.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, bem como VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, para a reforma em parte da sentença nos moldes da fundamentação. Condeno a União ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da condenação imposta em sentença. Sem honorários pela autora, porquanto vencedora, mesmo que em parte. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juízo de origem.